

1500604-58.2022.8.26.0019
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Furto
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/06/2022
... (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
2ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500604-58.2022.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500604-58.2022.8.26.0019
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2073709/2022 - 04º D.P. AMERICANA, 23659117 - 04º D.P. AMERICANA, 554/22/350 - 04º D.P. AMERICANA, 2073709 - 04º D.P. AMERICANA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ESMAEL DOMINGUES PEREIRA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

ESMAEL DOMINGUES PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput" e § 1º, c.c. artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, no período noturno, tentou subtrair, para si, uma caixa de som, marca "DONNER", e aproximadamente dez quilos de cabos elétricos, avaliados em R\$ 1.200,00, pertencentes à Paróquia São Francisco, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A denúncia foi recebida em 01 de abril de 2022 (fls. 122/123).
O réu foi citado, apresentando defesa (fls. 146/149).

Na audiência de instrução e julgamento, foi ouvida uma testemunha arrolada, bem como o réu foi interrogado (fls. 157/158).

Em memoriais em audiência, o Doutor Promotor de Justiça, entendendo estarem suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu pelo delito de furto qualificado.

A Doutora Defensora do réu requereu a aplicação da atenuante e, considerando ainda a ocorrência da tentativa, a fixação do regime mais brando (fls. 159/161).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de fls. 01, 06/08, e 09/15.

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho “é a certeza visual do crime”. A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:
“Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria” (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Na ocasião, o réu estava na posse do bem subtraído. A apreensão do bem subtraído em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, “De la Apreciación de las Pruebas”, tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJE, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, “La Prueba,

su Practica y Apreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJE, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita do bem. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. (...)." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

"(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a apreensão da "res" em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção se transmutar em certeza apta a ensejar o decreto condenatório (...)" (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria, j. 26.05.11);

PROVA - Furto - Apreensão da "res" em poder do agente - Presunção de responsabilidade - Entendimento: 31 (b) - Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. RJDTACRIM VOLUME 18 ABRIL/JUNHO 1993 PÁGINA: 66 RELATOR:- PASSOS DE FREITAS

O policial militar, ouvido em Juízo, esclareceu que, durante a madrugada, foram informados de um possível furto em andamento, tendo em vista o disparo de um alarme, e dirigiram-se até o local. No local, uma Igreja, o representante possibilitou o acesso e, em vistoria, localizaram o réu, escondido debaixo de uma mesa. Encontraram, ainda, próximo a janela, uma mochila, com objetos e fios já separados. Indagado, o réu confirmou a intenção de subtração.

O réu, ouvido em Juízo, confirmou a prática do furto, alegando que estava usando drogas e álcool, entrou por uma janela e tentou subtrair os objetos.

Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

"Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar

apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida." (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003). (AC 2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

De acordo com a Doutrina:

"É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, pag. 378/379).

Os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado, inclusive acerca da qualificadora (período noturno).

Referente a qualificadora do repouso noturno, em estabelecimento comercial, resta caracterizada, tendo em vista ter o agente utilizado de período de menor vigilância da vítima, não havendo de falar-se em qualquer afastamento.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que "incide a majorante prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando" (HC 191.300/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1546118/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

HABEAS CORPUS. FURTO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALDA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PENA-BASE. QUALIFICADORA SOBEJANTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INVASÃO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO CRIMINOSA. EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA AINDA QUE A VÍTIMA NÃO ESTEJA REPOUSANDO. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AFASTAMENTO DO ENUNCIADO N. 269 DA SÚMULA DESTA CORTE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - (...). IV - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando (HC 191.300/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 26/6/2012), devendo ser mantida, portanto, no caso. V - (...). (AgRg no HC 609.143/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021)

PENAL. FURTO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO CASO DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATÉRIA DE DIREITO. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. FURTO PRATICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...). 4. A majorante do §1º do art. 155 do Código Penal deve ser reconhecida mesmo nas hipóteses de furto praticado em estabelecimento comercial, tendo em vista a maior vulnerabilidade do patrimônio no período de repouso noturno. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1724452/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)

Verifica-se, também, que não há que falar-se em inimputabilidade em razão de consumo de substância entorpecente e/ou álcool. Primeiro, porque não comprovada. Segundo, porque a ingestão de bebida alcoólica, ou droga, só é excludente de culpabilidade se oriunda de fato culposo ou de força maior. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

DANO QUALIFICADO, DESACATO E LESÃO CORPORAL LEVE CIRCUNSTANCIADA, EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE, COM REDUÇÃO DAS PENAS. Materialidade e autoria dos delitos bem demonstradas nos autos (...). SEMI-IMPUTABILIDADE PENAL. Não há que se falar em inimputabilidade ou em semi-imputabilidade da apelante, pois tanto o artigo 28, §§ 1º e 2º, do Código Penal, como os artigos 45 e 46 da Lei nº 11.343/2006, exigem, para a isenção ou redução da pena, que a embriaguez, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, e a dependência ou o efeito de droga, sejam provenientes de caso fortuito ou força maior, e que o agente, em razão da embriaguez, dependência ou efeito de drogas, seja, ao tempo da ação ou omissão, inteira ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Já a embriaguez, voluntária ou culposa, como no presente caso, não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, inciso II). Adoção legislativa da actio libera in causa, de modo que, se o agente deu causa à embriaguez voluntária (o agente quis se embriagar) ou culposamente (o agente não queria embriagar-se, mas por imprudência chega àquele estado), ele responde pelos atos praticados em estado de ebriedade. (...). (TJSP; Apelação Criminal 1500190-16.2019.8.26.0585; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo Anastácio - Vara Única; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

APELAÇÃO FURTO QUALIFICADO. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento da realização de exame de dependência químico-toxicológica. Inocorrência. Ato justificadamente indeferido pelo magistrado no exercício de seu livre convencimento motivado - Mérito Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Condenação mantida. Pleito de isenção de pena, com encaminhamento a tratamento adequado à dependência química, nos termos do art. 45, da Lei n.º 11.343/06. Descabimento. Dispositivo legal que exige comprovação da inimputabilidade ou prática do delito sob efeito de drogas em razão de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica nos autos, não bastando a mera alegação de dependência química. (...). (TJSP; Apelação Criminal 0001976-42.2009.8.26.0288; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ituverava - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/10/2014; Data de Registro: 03/11/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Recurso defensivo - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos - Reconhecimento efetivado pela vítima e confissão parcial dos acusados que, aliados aos demais elementos de convicção, dão a certeza do cometimento do delito - Inimputabilidade que não restou comprovada - Eventual atuação delitiva sob efeito

ou dependência de droga que não decorreu de caso fortuito ou força maior -
Condenação mantida - (...). (TJSP; Apelação Criminal 0053723-90.2014.8.26.0050;
Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2016;
Data de Registro: 09/06/2016)

Por fim, o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, qual
seja, o de ter sido surpreendido pelos policiais.

Diante da robustez do conjunto probatório, a condenação do acusado pela prática de
furto é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas
(fls. 52/80) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-
base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes, por ele, indica a má
formação da personalidade, sempre voltada à prática de ilícitos criminais,
antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial.
Exaspero, por isso, a pena base em 1/6 (um sexto), considerado o mínimo,
delimitando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações
distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência:
"Cumpra precisar que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá
para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o
aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem."
(Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira
Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como
circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA
JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E
CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são
utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a
circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas
corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC
528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Na segunda fase, anoto que o réu é reincidente, circunstância agravante (artigo 61,
I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 52/80. Contudo, diante
da sua confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP), mantenho a pena em 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido.
(Resp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
10/04/2013, DJe 17/04/2013 - Tema 585, STJ)

Ainda, por força do que dispõe o § 1º, do artigo 155, do Código Penal, reconhecida
a causa de aumento do repouso noturno, ao furto acresço a pena em 1/3 (um terço),
perfazendo em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14

(catorze) dias-multa.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1721890/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA FIGURA TÍPICA BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DO DELITO QUALIFICADO COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...). III - Pedido de exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno. O entendimento consagrado neste eg. Superior Tribunal de Justiça é de que não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. A jurisprudência deste eg. Tribunal Superior é firme no sentido de que as normas que estabelecem as qualificadoras do furto e a causa de aumento do repouso noturno são harmonizáveis, haja vista que o legislador tanto nas qualificadoras objetivas (§ 4º do art. 155 do Código Penal) como na referida causa de aumento apreciou e revalorou o desvalor da ação do agente, e não fez uma análise sob a ótica do desvalor do resultado. Impende registrar que a causa de aumento de pena em comento, assim como as demais majorantes previstas no Código Penal e na legislação esparsa, nada mais são do que circunstâncias especiais erigidas pelo legislador infraconstitucional como de maior gravidade. Nesse contexto, a inserção na derradeira etapa da dosimetria apenas serve para cristalizar a maior reprovação da conduta, tendo em mente a existência de um procedimento sancionatório lógico, gradativo e escalonado. Precedentes: STJ e STF. IV - (...). Habeas corpus não conhecido. (HC 509.594/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019)

Tendo em vista que o delito se deu na forma tentada, diminuo a pena da 1/2 (metade), tendo em vista o iter criminis percorrido, perfazendo assim um total de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa.

Não é possível o reconhecimento do privilégio constante do § 2º, do artigo 155, do Código Penal em caso de furto qualificado. Além disso, para que o benefício fosse concedido, é requisito que o réu seja primário e portador de bons antecedentes. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA. EXPRESSIVO VALOR DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a aplicação da figura do furto privilegiado é necessário que o agente seja primário e de pequeno valor a coisa subtraída. 2. No caso, um dos réus é reincidente e o valor da coisa subtraída, somado ao prejuízo suportado pela vítima para o conserto de sua residência em razão do arrombamento, não pode ser considerado pequeno para fins de reconhecimento do privilégio pleiteado. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1511869/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REPOUSO NOTURNO. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 155, § 2º, do CP, constatada a reincidência do réu, mostra-se descabido o reconhecimento do furto privilegiado, bem como a consequente redução de pena dele decorrente. Precedentes. 2. Segundo jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno pode incidir tanto no furto simples quanto no qualificado, inexistindo incompatibilidade entre os institutos.

Precedentes. 3. Recurso parcialmente provido. (REsp 1724648/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)

FURTO QUALIFICADO - Aplicação do privilégio - Impossibilidade:117 - É impossível a aplicação do privilégio ao furto qualificado, vez que o agente de tal delito representa maior soma de perigo para a sociedade, tanto que o Legislador Penal teve o cuidado de tratar do benefício antes das circunstâncias qualificadoras. RJDTCRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 220 RELATOR: - THYRSO SILVA

Ademais, os péssimos antecedentes do réu desaconselham a adoção de tal benefício.

À míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência do réu.

O réu, por ser reincidente, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal condenar o réu ESMAEL DOMINGUES PEREIRA à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 07 (sete) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, "caput" e § 1º, c.c. artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal; bem como para condená-lo no pagamento das custas processuais, que fixo em 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Considerando que, em tese, o réu já esteve preso em período suficiente para eventual progressão de regime (art. 112, da LEP), concedo-lhe os benefícios da LIBERDADE PROVISÓRIA. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Desta forma, o réu poderá apelar em liberdade.

P. I. C.

Americana, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA